

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 323 A 326

Abandono de função

Assim aponta o Código Penal (art. 323):

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

OBSERVAÇÃO

Cargo público x Função pública

Cargo público e função pública não são a mesma coisa. A função pública é mais abrangente e engloba o cargo público. Além disso, a função pública considera todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, algum tipo de função perante a Administração Pública, como, por exemplo, os voluntários, os jurados e os mesários eleitorais.

Os cargos públicos são aquelas situações previstas na Lei n. 8.112, art. 3º, parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e com vencimentos pagos pelos cofres públicos.

ATENÇÃO

O abandono de outra função pública não constitui o tipo penal previsto no art. 323 do Código Penal. Portanto, o tipo penal do art. 323 deve incidir apenas sobre abandono de cargo público, fora dos casos permitidos em lei como, por exemplo, férias e licença prevista e autorizada.

Questão: Por quanto tempo deve se dar o abandono para que seja configurado o abandono?

Resposta: Há que se observar a situação que venha a ser gerada com o abandono.

ANOTAÇÕES

Exemplo: A ausência de um funcionário público que atua dentro dos Recursos Humanos de um determinado departamento público de 14:00 às 18:00 não gera qualquer tipo de risco à Administração Pública. Entretanto, a ausência de um policial judicial que atua em um tribunal, a partir de 14:00, pode colocar em risco a Administração Pública. Se o policial abandonasse o seu posto a partir das 14:00, o fórum ficaria desguarnecido, sujeito à ação de qualquer pessoa externa, que poderia colocar em risco as pessoas ali presentes.

A conduta do policial judicial deste último exemplo se enquadra na conduta do art. 323 do Código Penal.

Portanto, não há que se considerar o fator tempo para que se configure o abandono, e sim a situação que venha a ser gerada após o abandono.

Crime de perigo concreto

O abandono configura um crime de perigo concreto, ou seja, um crime que só vai se consumir quando houver, na prática, na análise do caso concreto, ou um perigo que venha a ser constatado.

Exemplo 1: Meia-hora após um policial judicial ter abandonado o fórum, uma pessoa armada tentou acessar o fórum.

Assim, uma situação de risco surgiu com um abandono de apenas meia-hora. Portanto, não há incidência do art. 323 sobre a conduta do policial judicial.

Exemplo 2: Durante quatro horas em que uma funcionária do RH se manteve afastada do seu setor de trabalho, não surgiu nenhuma situação que demandasse a sua intervenção. Assim, o fato de a funcionária ter se afastado durante quatro horas de seu local de trabalho não gerou prejuízo ou perigo de dano para a Administração Pública e nem para ninguém. Portanto, não há incidência do art. 323 sobre a sua conduta.

Crime omissivo próprio

O próprio tipo penal prevê uma conduta omissiva. Abandonar é uma conduta omissiva, uma vez que o indivíduo que abandona deixa de atuar no cargo público.

Por se tratar de uma omissão própria, o abandono é, portanto, um crime que não admite tentativa.

Crime formal

O crime de abandono de função se consuma independentemente de qualquer dano gerado à Administração Pública



5m

ANOTAÇÕES

Além disso, o abandono de função pode ser caracterizado como um crime de ação penal pública incondicionada e um crime de mão própria, ou seja, trata-se de uma conduta que não pode ser delegada a terceiros.

Qualificadora – Patamar de pena mínima e pena máxima

Parágrafo 1º - Crime material

Para que haja o *caput* do art. 323 (Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei), basta o perigo concreto, diante do abandono; para que haja a qualificadora do parágrafo primeiro (Se do fato resultar prejuízo público), deve efetivamente ser gerado um prejuízo público.

Portanto, diferentemente do *caput*, que versa sobre um crime formal, o parágrafo 1º versa sobre um crime material ou crime de dano e, por isso, deve ser gerado um prejuízo público para que haja a incidência da qualificadora.

Parágrafo 2º

Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira.

Exemplos:

- Auditor da Receita Federal que abandona o posto da alfândega;
- Policial Rodoviário Federal que deixa de atuar na zona de fronteira, uma região sensível onde muitos crimes são praticados.

Faixa de fronteira

A faixa de fronteira compreende 150 km de distância de largura contínua à linha territorial.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Assim aponta o Código Penal (art. 324):

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.



10m

ANOTAÇÕES

OBSERVAÇÃO

Crime de menor potencial ofensivo

Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. O crime do art. 324 é um crime funcional, ou seja, um crime praticado por funcionário público contra a Administração de maneira geral.

Funcionários públicos que exercem uma atividade ainda não autorizada por lei, não preenchidos os requisitos para que exerçam essa atividade, ou que prolongue a atividade da qual já foram destituídos.

ATENÇÃO

Não confunda o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado com o crime de usurpação de função pública, que ocorre quando um particular exerce as atividades de um outro funcionário público. No crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328 do Código Penal, um particular pratica atos funcionais como se funcionário público fosse.

Exemplo de crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado:

Um funcionário público recebeu uma função de confiança (cargo de chefia) em seu departamento. No entanto, a publicação em Diário Oficial da chefia obtida por esse funcionário seria feita somente no dia 1º de março.

Até a publicação no Diário Oficial, esse funcionário deveria permanecer atuando em sua função de origem. Entretanto, antes do dia 1º de março, data em que a chefia conquistada pelo funcionário público seria publicada no Diário Oficial, o funcionário passou a atuar como o chefe do departamento, praticando inclusive atos de ofício da chefia do departamento.

Crime de mão própria

O crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado é um crime de mão própria, ou seja, um crime que só pode ser praticado por um agente específico que ilegalmente antecipa a sua função ou a prolonga mesmo já tendo sido exonerado, removido, substituído ou suspenso. Portanto, essa conduta não pode ser delegada a terceiros.

Obs.: Em crimes de mão própria é possível que haja participação, mas não é possível que haja coautoria.

ANOTAÇÕES

Tentativa

É possível que haja a tentativa no crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, sem que haja o êxito de entrar ou permanecer no exercício da função pública por razões alheias à vontade do indivíduo.

Crime formal

O crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado se consuma ainda que o agente não tenha gerado qualquer prejuízo à Administração Pública.



Violação de sigilo funcional

Assim aponta o Código Penal (art. 325, *caput*):

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

OBSERVAÇÃO

Exemplo de revelação indireta: deixar um computador aberto para a revelação de informações sigilosas.

Exemplo de revelação direta: Um funcionário público que atua em uma investigação criminal sigilosa revelou a um terceiro os detalhes da investigação.

Crime formal

Independentemente de gerar ou não danos, a revelação de uma informação sigilosa configura a prática do delito de violação de sigilo funcional.

Crime próprio

O delito de violação de sigilo funcional só pode ser praticado pelo próprio funcionário público, ainda que aposentado.

Exemplo: Funcionário que atua na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), após se aposentar como agente da ABIN, caso revele informações sigilosas, incorre no delito de violação de sigilo funcional.

Apesar de o funcionário aposentado ter praticado a conduta delituosa em um momento em que não era mais funcionário público, há que se considerar que os fatos sigilosos e o segredo que deveria ser guardado se deu em razão das funções que antes exercera.

ANOTAÇÕES

Crime doloso

O delito de violação de sigilo funcional só pode ocorrer na modalidade dolosa.

Exemplo: Um funcionário enviou, sem querer de maneira imprudente, um e-mail com informações sigilosas para um destinatário errado, revelando um segredo.

Neste caso, o funcionário pode ser punido administrativamente. Entretanto, não há que se falar em incidência de crime, pois a revelação do segredo se deu de maneira culposa.

Tentativa

O delito de violação de sigilo funcional cabe tentativa. Dessa forma, é possível que um funcionário tente revelar um fato sigiloso e não alcance a revelação por razões alheias à sua vontade.

Assim aponta o Código Penal (art. 325, §§ 1º e 2º):

Art. 325 – (...)

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

OBSERVAÇÃO

O mero fato de emprestar senha ou permitir o acesso de uma pessoa não autorizada a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública configura violação de sigilo funcional.

Além disso, a utilização do acesso restrito para benefício próprio ou para repasse de informações sigilosas para parentes ou pessoas próximas configura violação de sigilo funcional

Parágrafo 2º - Qualificadora do sigilo funcional e crime material

A qualificadora somente será aplicada se efetivamente, da conduta comissiva ou omissiva praticada, resultar dano à Administração Pública ou a outrem.



20m

ANOTAÇÕES

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Assim aponta o Código Penal (art. 326):

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – Detenção, de três meses a um ano, e multa.

OBSERVAÇÃO

O art. 326 do Código Penal foi revogado tacitamente pela Lei n. 8.666 (Antiga Lei de Licitações) e também pela Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

Portanto, a aplicação prática do conteúdo do art. 326 não se encontra mais dentro do Código Penal.

Diante da violação do sigilo de proposta de concorrência, não deverá mais ser aplicado o art. 326 do Código Penal, e sim o art. 337-J do Código Penal.

Violação de sigilo em licitação (Incluído pela Lei n. 14.133, de 2021)

Assim aponta o Código Penal (art. 337-J):

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: (Incluído pela Lei n. 14.133, de 2021)

Pena – detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
